

노동관행론*

김 성 진**

목 차

- | | |
|-----------------|-----------|
| I. 문제의 제기 | IV. 관련 문제 |
| II. 노동관행의 법적근거 | V. 결론 |
| III. 노동관행의 성립요건 | |

I. 문제의 제기

노동관행 혹은 노사관행이란 노동관계의 영역에서 근로조건이나 직장규율 등에 관한 어떤 사실이나 행위가 명시적인 규정에 의하지 않거나 혹은 그에 반하여 노사 간에 상당기간 이의 없이 반복해서 행해짐으로써 사실상 상당한 정도의 규범력을 얻게 된 것을 말한다. 노동관행은 민사의 영역에서 관습법이나 사실인 관습이 규범으로서 일정한 역할을 하듯이 노동관계의 영역에서 규범으로서 상당한 역할을 하고 있다. 예컨대, 대법원은 사용자가 별도의 근거 규범이 없는 상태에서 근로자에게 상당기간 반복적으로 특정의 수당을 지급하는 경우에 정기적이고 반복적으로 지급되는 사실 그 자체를 노동관행으로 인정하고 그것을 근거로 해당 수당에 대한 사용자의 지급의무를 인정한다.¹⁾ ‘근로의 대가’라는 임금개념의 주요 판단요소 중에 ‘지급의무성’

DOI: <https://doi.org/10.46329/LLF.2024.03.41.27>

논문투고일자: 2024.02.14., 심사일자: 2024.03.11., 게재확정일자: 2024.03.12.

* 이 논문은 2023년도 전북대학교 연구기반조성비 지원에 의하여 연구되었음

** 전북대학교 법학전문대학원 교수, 법학박사, 변호사

1) 대법원 1997. 5. 28. 선고 96누15084판결 등

을 노동관행에 의해서 인정하고 있는 것이다.

규정에 근거하지 않은 불문의 규범은 일반적인 민사의 영역보다 노동관계의 영역에서 더 많이 발생할 수밖에 없다. 그 이유로는 첫째, 민사에서의 불문법은 전체 사회 영역에서 발생하나 노동관계는 부분 사회에 불과하므로 일정한 노동관행의 성립요건을 충족하기가 쉽다. 둘째, 근로관계는 계속적 채권관계로서 당사자들 간에 다양한 사실행위들이 반복·계속될 여지가 상존한다. 셋째, 근로관계에서의 급부내용은 사용자에 의해서 일방적으로 정해지거나 사업의 변화에 따라서 다양하게 변화할 수 있기 때문에 규정에 근거하지 않은 사실들이 얼마든지 발생할 수 있다. 넷째, 노동관계 영역은 강행규정 외에도 단체협약이나 취업규칙, 근로계약 등 다양한 임의규정이 존재하므로 이를 따르지 않는 사실행위들이 발생할 여지가 많다.

한편, 노동관계에서 노동관행이 규범으로서 차지하는 위상이 상당함에도 어떤 사실에 대해서 노동관행의 성립을 인정하고 그에 대해서 규범력을 부여하는 근거가 무엇인지에 대해서는 학계나 실무의 논의가 명확하지는 않다. 법원의 판례 역시 다양한 유형의 사안에 대해 어떤 기준으로 노동관행의 성립을 인정할 것인지에 관해서 일관된 판결을 하고 있는 것으로 보이지는 않는다. 존재하는 반복적 사실에 대해서 노동관행으로 인정하고 규범력을 부여하는 역할은 궁극적으로 법원이 한다는 측면에서 보면 이에 대한 법원의 역할이 중요하다.

이러한 문제의식을 기반으로 이하에서는 노동관행의 법적근거에 관한 논의를 살펴본 후 그 근거(신뢰책임)를 명확히 하고자 한다. 그 연장선상에서 노동관행의 성립요건에 관한 논의를 전개한 후에 다양한 경우에 있어서 노동관행의 성립기준을 명확히 정립하고자 한다. 관련 논의에 있어서는 기존의 노동관행에 대한 대법원의 판결내용이 적절한 것인지에 대해서도 검토한다.

Ⅱ. 노동관행의 법적근거

민법 제1조는 “민사에 관하여 법률에 규정이 없으면 관습법에 의하고, 관습법이 없으면 조리에 의한다.”고 규정하여 민사의 영역에서는 법률이 없을 경우 관습법도 하나의 법규범으로 인정되고 있다. 또한 민법 제106조(사실인 관습)는 “법령 중의 선량한 풍속 기타 사회질서에 관계없는 규정과 다른 관습이 있는 경우에 당사자의 의사가 명확하지 아니한 때에는 그 관습에 의한다.”고 규정하여 사실인 관습이 임의규정을 보충하는 효력을 인정하고 있다.

노동관계 영역 역시 넓게 보아 민사에 관한 영역에 포함된다고 보면 위와 같은 민법의 규정이 적용될 수 있겠지만, 노동관계 영역은 앞서 기술한대로 일반 민사의 영역보다는 노동관행이 더 많이 발생할 수밖에 없는 특징이 존재하므로 노동관행에 대해서는 별도의 취급을 하는 것이 일반적이다. 그 경우 노동관행에 대해서 어떠한 근거에 의해 규범력을 인정할 것인지에 대해서는 크게 계약설과 신뢰책임설이 제시되고 있다.

1. 계약설

이 견해는 일정한 사실의 반복으로부터 당사자의 의사를 추출하여 묵시적 합의 혹은 묵시적 계약을 이끌어 낸다. 예컨대, 사용자가 별도의 근거규정이 없음에도 근로자에게 일정한 급부를 반복적으로 하는 경우에 사용자는 그와 같은 행위의 반복을 통해 앞으로도 계속하여 그와 같은 급부를 하겠다는 청약의 의사가 내재된 행위를 한 것으로 보고, 근로자는 당해 급부를 반복적으로 수령하는 것에 관하여 묵시적인 승낙을 한 것으로 보는 것이다.²⁾

한편, 노동관행을 사실인 관습으로 보는 견해³⁾ 역시 사실상 계약

설과 같은 설명을 하고 있다. 이에 따르면 임의법규와 다른 사실인 관습(민법 제106조)⁴⁾은 사회의 법적확신이나 인식에 의하여 법적규범으로 승인된 정도에 이르지 못한 경우를 말하는데, 이는 당사자가 명확히 의사를 정한바가 없는 경우에 당사자의 묵시적 의사를 추정하는 것으로 사실상 계약설과 궤를 같이한다.

2. 신뢰책임설

이 견해는 노동관행이 규범력을 발생하는 근거를 당사자의 신뢰보호에서 찾는다. 즉 일방 당사자에 의해서 일정한 사실적 급부가 반복되는 경우에 상대방 당사자는 앞으로도 그와 동일한 급부를 계속 받게 될 것이라는 기대와 신뢰를 갖게 되고 그러한 신뢰는 보호되어야 한다는 것이다. 그리고 이 경우 당사자의 신뢰는 신의칙이라는 객관적 규범을 매개로 하여 보호되고 그에 따라 노동관행은 규범력을 발생한다고 한다.⁵⁾ 이 견해에 따르면 노동관행의 성립을 위해서 당사자들의 의사는 고려되지 않고 신의칙이라는 객관적 규범을 통해서 규범

2) 대표적인 견해; 권혁, “노동관행에 따른 급부청구권의 형성과 소멸”, 「노동법학(제23호)」, 한국노동법학회, 2006. 12

3) 대표적인 견해; 박홍규, 「고용법·근로조건법(제2판)」, 삼영사, 2005, 238쪽

4) 관습법과 사실인 관습의 구별에 관하여는 대법원 1983. 6. 14. 선고 80다3231판결; “관습법이란 사회의 거듭된 관행으로 생성한 사회생활규범이 사회의 법적 확신과 인식에 의하여 법적 규범으로 승인·강행되기에 이르는 것을 말하고, 사실인 관습은 사회의 관행에 의하여 발생한 사회생활 규범인 점에서 관습법과 같으나 사회의 법적 확신이나 인식에 의하여 법적 규범으로서 승인된 정도에 이르지 않은 것을 말하는 바, 관습법은 바로 법원으로서 법령과 같은 효력을 갖는 관습으로서 법령에 저촉되지 않는 한 법칙으로서의 효력이 있는 것이며, 이에 반하여 사실인 관습은 법령으로서의 효력이 없는 단순한 관행으로서 법률행위의 당사자의 의사를 보충함에 그치는 것이다.”

5) 대표적인 견해; 하경호, 「노동법 사례연습」, 박영사, 2008; 신권철, “노동관행 소고 - 통상임금 산정관행을 중심으로 -”, 「노동법학(제48호)」, 한국노동법학회, 2013. 12, 253쪽

력이 인정되므로 신규 입사자에게도 노동관행이 적용될 수 있다는 점을 설명할 수 있다.

3. 판례의 입장

노동관행을 다룬 대법원의 판례들을 분석해보면 대법원이 노동관행의 규범력을 인정하는 근거로 두 가지 기준을 사용하고 있는 것을 알 수 있다.

첫째, 노동관습설 혹은 법적확신설로 알려진 기준으로 전적에 관한 사안에서 처음 사용되었다. 해당 판결⁶⁾에서 대법원은 “사용자가 근로자의 동의를 얻지 아니하고 기업그룹내의 다른 계열회사로 근로자를 전적시키는 관행이 있어서 그 관행이 근로계약의 내용을 이루고 있다고 인정하기 위하여는 그와 같은 관행이 기업사회에서 일반적으로 근로관계를 규율하는 규범적인 사실로서 명확히 승인되거나, 기업의 구성원이 일반적으로 아무런 이의도 제기하지 아니한 채 당연한 것으로 받아들여 기업 내에서 사실상의 제도로서 확립되어 있지 않으면 안 된다”고 하였다. 이와 같은 판례의 기준처럼 노동관행을 인정하는 근거 혹은 요건으로 관습법에서 요구하는 법적확신 혹은 그에 준하는 정도의 규범의식을 요구할 경우 노동관행의 성립범위는 좁아질 수밖에 없다. 그에 따라 이러한 기준을 사용하는 판례사안들 중에는 노동관행으로 인정된 경우가 존재하지 않는다. 일부 판결⁷⁾을 보면 대법원이 구체적인 사안에서 노동관행을 인정하지 않기 위해서 일부러 그와 같은 엄격한 기준을 사용하고 있는 것은 아닐까 하는 생각이 들기도 한다. 이러한 판결들로 인해서 대법원이 노동관행의 인정범위나

6) 대법원 1993. 1. 26 선고 92다11695 판결

7) 대법원 2014. 2. 27. 선고 2011다109531판결; 대법원 2014. 2. 27. 선고 2011다109531판결; 대법원 2002. 4. 23. 선고 2000다50701판결 등

기준을 너무 협소하게 혹은 엄격하게 적용한다는 비판을 하는 견해⁸⁾도 있다. 그러나 다음의 내용을 보면 대법원이 노동관행 인정기준을 부적절하게 잘못 적용한 경우는 있을지언정 엄격하거나 협소하게 적용하고 있다고 볼 것은 아니다.

둘째, 대법원이 노동관행을 인정한 상당수의 사안을 보면 반복되는 관행으로부터 당사자 사이의 묵시적 합의가 인정된다는 표현을 사용하는 경우가 많다.⁹⁾ 이들 사안들을 보면 대체로 임금에 관한 사안들이 많은데, 사안에 따라서는 노동관행으로 인정되지 않아야 할 사안에서조차도 당사자 사이의 묵시적 합의를 추단하여 노동관행으로 인정하는 경우도 있다. 대법원이 묵시적 합의를 추단하는 것은 해당 관행을 사실인 관습으로 보고 법적확신의 정도를 완화하는 해석을 한 것으로 볼 수도 있는데, 이는 임의규정의 영역에서만 가능하다는 점에서 보면 대법원이 강행규정의 영역에서도 그와 같은 기준을 적용하는 경우도 있어서 일관성이 떨어진다.

이와 같이 대법원이 두 가지 기준을 가지고 노동관행의 규범력의 근거를 삼고 있는 것을 보면 대법원이 이에 대해서 명확한 입장을 가지고 있는 것으로 볼 수는 없다. 일부 견해들¹⁰⁾은 이에 대해 대법원이 관습법과 사실인 관습을 구별하고 있지 않다고 평가하기도 한다. 사실 노동관행에 관한 대법원 판결의 문제는 대법원이 노동관행의 인정 근거에 관한 명확한 입장이 존재하지 않다보니 개별 사안들에 있어서 일관된 기준에 의한 판결이 이루어지지 않는데 있다.

8) 권혁의 논문 286쪽; 박수근, “노동관행의 규범성과 단체협약의 소급적 효력”, 「노동판례비평」, 민주사회를 위한 변호사 모임, 2002, 134쪽

9) 대법원 2001. 10. 23. 선고 2001다53950판결; 대법원 2013. 12. 18. 선고 2012다89399판결 등

10) 이상윤, 「노동법(제6판)」, 법문사, 2011, 38쪽; 이병태, 「최신노동법(제9전정판)」, (주)중앙경제, 2008, 48쪽

4. 검토

(1) 계약설은 다음과 같은 점에서 설득력이 떨어진다.

첫째, 객관적으로 반복된 급부지급사실로부터 사용자의 의무부담 의사를 바로 인정하는 것은 지나치게 작위적이다.¹¹⁾

둘째, 설사 반복된 사실로부터 사용자의 의사를 추출하는 것이 가능하더라도 해당 사실이 처음 시작되었을 때부터 사용자의 의무부담 의사가 생기지는 않았을 것이고, 어느 시점에서부터 의무부담에 대한 인식이 생겼을 것이라고 가정하더라도 그 시점을 특정하기는 쉬운 일이 아니라는 점에서도 설득력이 없다.

셋째, 반복된 사실 중에서 그 동안의 계속된 사실에 대해서는 묵시적 합의 등 의사표시 해석의 방법으로 해석해낼 수 있지만, 미래의 지급의무를 규율하는 관계는 양 당사자의 묵시적 합의를 쉽사리 도출해 낼 수 없다.¹²⁾

넷째, 독일에서 논의되고 있는 계약설에 대한 설명¹³⁾에 의하면 사용자의 청약으로서의 의사는 사용자가 아닌 근로자의 주관적 의사에서 발생한다. 즉 사용자는 근로자에게 “사용자가 스스로 종래 반복된 급부의 지급을 의무로서 부담하려고 한다.”는 주관적 판단을 가능하게 하였다면 사용자의 의사를 인정한다는 것이다. 그런데 이러한 계약설의 설명은 사실상 신뢰책임설에 합당한 논리가 아닐까? 근로자의 그러한 판단은 그 동안의 반복된 사실로부터 앞으로도 그러한 지급이 계속될 것을 예상·기대하는 경우에 생기는 것이기 때문이다.

다섯째, 노동관행의 규범력이 문제되는 경우는 당사자 일방이 그 동안의 관행적 사실에 반하는 행위를 하는 경우에 그 동안의 관행에

11) 권혁의 논문, 284쪽

12) 신권철의 논문, 242쪽

13) 자세한 설명은 권혁의 논문, 289쪽

비추어 그에 반하는 행위를 규율할 수 있는지 여부다. 이 경우 계약설에 의하면 관행적 사실의 변경에 맞추어 당사자의 의사를 일관되게 설명하기가 어렵다. 예컨대, 크리스마스 상여금을 수차례 지급해온 관행이 있더라도 그것이 노동관행으로 인정되는지 문제되는 시점은 사용자가 지급을 거절하고 그에 대해서 근로자가 제소하는 경우다. 계약설에 의하면 이 시기는 이미 사용자의 의사가 변경된 경우로 볼 수 있는데, 당사자 일방의 의사가 이와 같이 일관성이 없는 상황에서 노동관행으로 인정하는 것은 논리적이지 않다.

(2) 노동관행에 규범력을 인정하는 근거에 대해서는 다음과 같은 점에서 보면 신뢰책임으로 이해하는 것이 타당하다.

첫째, 노동관행이 인정되는 과정을 보면 당사자 일방의 ‘호의성(임의성)’에 기초한 어떠한 사실(예컨대, 사용자의 호의에 따른 특별생산 격려금의 지급, 근로자의 호의에 기초한 근무시간 후의 작업장 정리와 청소 등)이 어느 정도 반복되는 과정을 통해서 ‘법률관계(권리·의무관계)’로 전환된다. 이 경우 당사자 일방의 ‘호의성’이 어느 순간 ‘의무성’으로 대체될 수 있다는 설명은 자연스럽지 못하다.¹⁴⁾ 그러한 과정을 설명하기 위해서는 별도의 촉매제가 필요하다.

둘째, 호의에 기초한 어떤 사실의 누적에 노동관행을 통해 의무로 인정된다는 것은 객관적인 규범성이 인정된다는 것이므로 촉매제로서의 역할을 하는 것은 외부의 사정으로부터 찾아야 한다. 그러한 외부의 사정은 상대방의 행위에 대한 신뢰 또는 자신의 행위에 대한 상대방의 신뢰에서 찾을 수 있다.

14) (이 글의 뒤에서 다루는)당사자의 부작위(권리의 불행사)에 의한 신뢰의 발생과 노동관행이 인정되는 과정도 마찬가지다. 당사자는 이의제기나 권리를 행사할 수 있음에도 불구하고 임의적으로 권리를 행사하지 않는 상태가 반복되고 그에 대해 상대방은 신뢰를 얻게 된다. 이 경우 당사자 일방의 임의성이 어느 순간 ‘법률관계’로 전환(권리의 상실과 상대방의 면책)되는 논리는 부자연스럽다.

셋째, 이 견해에 대해서는 근로자에게 유리한 경우에는 설명이 가능하나, 불리한 경우에는 설명이 어렵다는 비판이 있다.¹⁵⁾ 그러나 노동관행이 규범력을 발휘하는 이상 당사자 사이의 유·불리에 의해서 판단되어질 것은 아니라는 점에서 설득력 있는 비판은 아니다.

(3) 노동관행의 인정근거에 관한 대법원의 태도에 대해서는 다음과 같은 평가가 가능하다.

먼저, 일부 견해처럼 대법원의 입장을 노동관습설 혹은 법적확신설이라고 볼 경우라면 그러한 대법원의 태도는 적절하다고 할 수 없다. 앞서 지적한 것처럼 노동관계의 영역은 민사의 영역보다 노동관행이 성립할 가능성이나 인정될 필요성이 훨씬 크기 때문이다. 그럼에도 불구하고 관습법이나 관습법에 준하는 정도의 기준을 적용하는 것은 부당하다고 할 것이다. 부분사회인 노동관계 영역에서의 노동관행의 성립의 근거는 양쪽 당사자의 법적확신이나 그에 준하는 정도의 규범의식을 요구할 필요는 없고, 부분사회 내에서의 당사자 일방의 신뢰나 기대로도 충분하다고 보아야 한다.¹⁶⁾

다음으로, 대법원이 노동관행 인정의 근거로 어떤 확립된 입장을 가지고 있지 않다는 것을 전제로 하면 그 연장선상에서 대법원이 노동관행 인정의 근거로 신뢰책임을 배제하고 있다고 볼 필요는 없다. 예컨대, 2013년의 통상임금에 관한 대법원 전원합의체 판결의 다수의 견은 당사자 간의 명시적 혹은 묵시적 합의를 근거로 노동관행을 인정하는 취지의 논리를 전개하였고, 이에 대해서 소수의견은 신뢰책임론으로 반론하고 있다.¹⁷⁾ 또한 대법원은 계약갱신에 관한 규정이 없

15) 권혁의 논문, 285쪽

16) 유사한 취지의 견해; 신권철의 논문, 254쪽은 대립되는 이해관계의 장에서 공통적인 법적 확신의 성립은 어렵지만, 적어도 기대나 예견을 통한 규범의식의 성립은 가능하다고 한다.

17) 대법원 2013. 12. 18 선고 2012다89399(전원합의체)판결; “이와 관련하여 다수의견

더라도 해당 사업장이나 당사자 간의 계약갱신의 실태 등의 사정을 종합하여 당사자 간에 근로계약의 갱신에 대한 신뢰가 형성된 경우에 갱신기대권을 인정¹⁸⁾하고 있는데, 이 역시도 반복된 사실에 대해서 신뢰형성을 근거로 규범의 성립을 인정하고 있는 것으로 신뢰책임에 근거한 노동관행의 인정논리로 설명될 수 있다.

Ⅲ. 노동관행의 성립요건

노동관행에 대해서 규범력을 인정하는 근거를 신뢰책임에서 구한다고 할 때, 노동관행이 성립되기 위해서는 ① 일정한 사실행위의 지

은 상여금의 연원, 그 성질의 불명확성, 고용노동부의 지침 등으로 인하여 정기상여금을 통상임금에서 제외하기로 하는 노사합의가 관행으로 정착되어 왔다는 사정을 근거로 들고 있다. 그러나 이 사건에서 이러한 노사합의가 관행으로 정착되어 왔다는 사정을 인정할 근거자료를 찾아볼 수 없다. 단지 그러한 관행이 있는 것으로 보인다고 다수의견이 사용자의 관점에서 일방적으로 추정하고 있을 뿐이다. ... 나아가 이러한 노사합의의 관행이 있다고 하더라도 이를 근로자의 신뢰 공여로 평가할 수 없다. 근로기준법의 강행규정은 그 규정의 존재를 알지 못하거나 이를 제대로 이해하지 못한 자에게도 일률적으로 적용되고, 법률의 부지(불지)나 법적 평가에 관한 착오가 있다고 하여 그 적용을 피할 수 없다. 강행규정에 위반되어 무효인 노사합의의 관행이 있더라도 그러한 관행이 근로자에 의하여 유발되거나 그 주된 원인이 근로자에게 있지 아니한 이상, 그와 같은 무효인 노사합의의 관행이 강행규정에 반하여 무효라고 주장하지 않으리라고 사용자가 신뢰하는 것이 정당화될 수 없다. 그와 같은 사용자의 신뢰는 보호할 만한 가치가 있는 것이 아닐 뿐만 아니라, 이를 먼저 보호하게 되면 법에 위반된 관행을 강행규정에 우선시키는 결과를 초래하기 때문이다.”

- 18) 대법원 2011. 4. 14 선고 2007두1729 판결; “그러나 근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에서 기간만료에도 불구하고 일정한 요건이 충족되면 당해 근로계약이 갱신된다는 취지의 규정을 두고 있거나, 그러한 규정이 없더라도 근로계약의 내용과 근로계약이 이루어지게 된 동기 및 경위, 계약 갱신의 기준 등 갱신에 관한 요건이나 절차의 설정 여부 및 그 실태, 근로자가 수행하는 업무의 내용 등 당해 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합하여 볼 때 근로계약 당사자 사이에 일정한 요건이 충족되면 근로계약이 갱신된다는 신뢰관계가 형성되어 있어 근로자에게 근로계약이 갱신될 수 있으리라는 정당한 기대권이 인정되는 경우에는, 사용자가 이를 위반하여 부당하게 근로계약의 갱신을 거절하는 것은 부당해고와 마찬가지로 아무런 효력이 없고, 이 경우 기간만료 후의 근로관계는 종전의 근로계약이 갱신된 것과 동일하다.”

속, ② 신뢰 혹은 기대의 발생이 필요하다.

1. 일정한 사실행위의 지속

(1) 어떠한 사실이 노동관행으로 인정되기 위해서는 계속·반복적으로 그 행위가 이루어져야 한다. 사실의 반복이 어느 정도로 계속되어야 상대방 당사자의 신뢰를 발생시킬 수 있을 것인가에 대해서는 확실적인 기준에 따라 일률적으로 단정할 수는 없다.¹⁹⁾ 보통은 5년 이상 특정한 행위가 반복 계속되어야 노동관행을 인정할 수 있다는 견해²⁰⁾도 있지만, 판례에서 인정된 사례들은 천차만별이다. 그럼에도 불구하고 일반적으로 다음의 두 가지 기준을 제시할 수 있다.

먼저, 사실행위의 유형(자세한 논의는 2.항의 요건에서 설명한다)에 따라서 반복의 정도가 달리 인정되어야 한다. 반복된 사실이 상대방의 ‘작위’(적극적인 행위)에 해당할 경우에는 상대방의 ‘부작위’²¹⁾(소극적인 행위 혹은 권리 불행사)에 의한 기간이나 정도보다 작아도 노동관행이 인정될 수 있다. 상대방의 작위로부터 오는 기대는 보다 직접적으로 발생하므로 반복의 정도가 덜 해도 무방하다. 그에 비해서 상대방의 부작위에서 오는 기대를 인정해주기에는 (뒤에서 설명하듯) 여러 가지 신중히 판단할 문제가 있으므로 반복의 정도나 기간이 훨씬 더 길어질 수밖에 없다.

다음으로, 사실행위가 발생하는 영역에 따라 반복의 정도는 달라질 수 있다. 첫째, 규범이 존재하지 않는 영역에서는 존재하는 곳보다 사실의 반복의 정도가 덜 해도 된다. 규범이 존재할 경우에는 그

19) 하경효의 책, 83쪽

20) 박홍규의 책, 238쪽

21) 통상 ‘부작위’를 법률용어로 쓸 때는 ‘어떤 행위를 해야 할 의무가 있는 사람이 이를 하지 않는 것’으로 쓰지만, 여기서는 단지 ‘소극적으로 어떤 행위를 하지 않는 것’의 의미로 쓴다.

규범을 넘어서야 노동관행이 성립될 수 있기 때문이다. 둘째, 규범이 존재하는 영역에서는 존재하는 규범의 종류(강행규정 혹은 임의규정)에 따라 달라질 수 있다. 당연히 강행규정의 영역보다 임의규정의 영역에서 사실의 반복정도가 덜하다. 셋째, 단일 기업 내부에서의 관행보다 더 광범위한 노동관계 영역에서 발생하는 노동관행의 성립은 반복의 강도가 훨씬 크고 광범위하다고 보아야 한다.

(2) 노동관행이 인정되기 위해서는 사실의 반복이 당사자의 임의성(또는 호의)에 기초하여야 한다. 당사자의 사실행위가 근로계약이나 취업규칙, 단체협약, 법령 등 법적근거가 있는 행위에 기해 이루어지는 것은 법률관계에 따른 의무의 이행에 불과한 것이기 때문에 노동관행 성립의 기초를 이루는 사실행위라 할 수 없다. 마찬가지로, 반복적 사실이 있더라도 당사자의 유보나 명시적인 배제가 있는 경우(예컨대, 임의성에 대한 시한의 설정이나 임의성이 적용되는 대상의 제한 등)에는 노동관행이 성립될 수 없다.²²⁾

한편, 당사자가 착오로 법률, 단체협약 또는 계약상의 급부의무가 있는 것으로 잘못 알고 일정한 지급을 반복적으로 계속한 경우에는 당사자가 그와 같은 의무의 부존재를 모르고 있는 한 구속력을 가지는 노동관행은 성립할 수 없다. 이 경우는 당사자의 자발적 의사(임의성)가 없기 때문에 이에 대한 상대방의 신뢰는 신의칙상 보호받을 수 없다.²³⁾ 노동관행 인정의 근거인 신뢰책임이 상대방의 신뢰라는 객관적인 기준에 의해서 인정되는 것이긴 해도 민법상의 착오이론에 의하면 상대방보다는 착오를 일으킨 당사자를 우선적으로 보호하는 것이 원칙이기 때문이다.

22) 하경효의 책, 77쪽

23) 김형배, 「노동법(제27판)」, 박영사, 2021, 100쪽

2. 상대방의 기대 혹은 신뢰의 발생

(1) 일정한 사실행위의 반복으로부터 상대방 당사자의 기대 혹은 신뢰가 형성되어야 노동관행이 인정될 수 있다. 예컨대, 사용자가 지급의무가 없음에도 수년간 크리스마스 상여금을 근로자들에게 지급한 경우에 근로자들로서는 앞으로도 매년 해당 상여금을 받을 수 있을 것이라는 기대가 발생할 것이고 이는 노동관행으로 인정되어 근로자들에게 상여금에 대한 급부청구권을 발생시킨다. 처음에는 호의적인 지급으로 시작되었던 것이 계속된 급부의 반복으로 상대방에게 신뢰를 발생시키고 그에 근거하여 사용자와 근로자간에 권리·의무관계가 형성되는 것이다.

(2) 상대방의 기대와 신뢰는 주로는 일방 당사자의 작위(적극적 행위)에서 비롯된다. 사용자가 근로자들에게 크리스마스 상여금을 지급하는 경우처럼 일방 당사자의 적극적인 행위는 상대방의 기대와 신뢰를 발생시킨다.

근로자의 작위로부터도 사용자의 기대와 신뢰를 발생시킬 수 있을까? 예컨대, 근로자들이 반복적으로 근무시간 전에 일찍 출근하여 작업준비를 하거나 업무시간 종료 후에 작업장을 정리하는 경우에 그로부터 사용자의 기대가 형성되고 그에 따른 노동관행이 성립된다고 볼 수 있는가의 문제다. 이에 대해 근로계약관계에서 근로자의 의무에 해당되는 내용을 명문의 규정 없이 사용자가 단지 신뢰하였다는 이유만으로 근로자의 부담을 의무화하는 것은 인정할 수 없다는 견해²⁴⁾가 있다. 이 견해는 신뢰책임이 발생하기 위한 당사자의 신뢰는 법적으로 보호가치가 있는 신뢰이어야 하는데 사회적 약자로서 근로자보호를 이념으로 하는 노동법에서는 그러한 사용자의 신뢰를 보호대상으

24) 권혁의 논문, 285-286쪽

로 인정할 수 없다고 한다. 그러나 노동관행에 대해서 법적구속력을 인정하는 근거를 신뢰책임에서 구하는 이상 사용자의 신뢰라고 하여 배제할 것은 아니다. 노동관행이 신의칙에 근거한 객관적인 법규범으로 인정되기 위해서는 사용자의 기대도 객관적으로 보호되어야 한다. 해당 전해가 우려하는 근로자보호의 문제는 노동관행이 인정되는 기본 전제가 당사자의 임의성에 기댄 급부행위에서 비롯되는 것이므로 근로자의 임의성에 기댄 의무부담행위에 대해서는 굳이 근로자보호의 법리를 적용하지 않아도 될 것이다. 만약 그러한 근로자들의 행위가 사용자의 명시적 혹은 묵시적인 지시에 의해서 이루어진 것이라면 노동관행이 성립될 수 없다. 또한 근로자가 착오로 급부의무가 있는 것으로 알고서 그러한 행위를 한 경우에도 노동관행은 성립될 수 없으므로 이 문제에 있어서 근로자보호의 문제가 달리 발생할 여지는 없을 것이다.

(3) 상대방 당사자의 ‘부작위’(소극적 행위 혹은 권리 불행사)로부터 기대와 신뢰가 형성될 수 있을까? 예컨대, 사용자가 근로자에게 지급해야 할 임금을 반복적으로 지급하지 않는 경우에 이에 대해서 근로자는 미지급 임금의 지급을 청구할 수 있음에도 불구하고 장기간 임금의 지급을 청구하지도 않고 아무런 이의제기를 하지 않는 경우에 그로부터 사용자가 더 이상 근로자가 임금의 지급을 청구하지 않을 것이라는 기대와 신뢰를 형성하여 그에 대해 노동관행을 인정할 수 있을 것인가의 문제다. 이 문제는 기대와 신뢰를 주장하는 사용자가 근로자의 권리 불행사의 원인 제공자라는 점에서 또한 이러한 사용자의 기대에 대해 노동관행을 인정할 경우에 일방 당사자인 사용자는 의무이행에 대한 면책의 이익을 얻는 반면에 상대방 당사자인 근로자는 권리를 잃는 손해를 입게 된다는 점에서 신중한 판단이 필요하다.

이에 대해서는 근로관계에서 수동적 지위에 있는 근로자에게 적극적으로 자신의 의사를 개진하도록 의무를 부과할 수 없다는 점, 사법

적 계약관계에서 당사자의 침묵은 곧 거절을 의미한다는 점에서 노동관행을 인정할 수 없다는 견해가 있다.²⁵⁾ 그러나 노동관행은 객관적으로 당사자가 갖게 되는 기대와 신뢰를 근거로 인정되는 규범이고, 그것은 가치중립적인 것이어서 그것을 누가 갖게 되는지는 고려의 대상이 아니다.²⁶⁾ 또한 해당 견해의 주장대로 ‘침묵’과 관련한 의사표시 해석의 논리로 접근하더라도 마찬가지다. 사용자의 의무불이행에 대해서 ‘거절’의 의사를 관철하기 위해서는 적극적인 이의제기나 권리주장이 필요한 것임에도 만약 침묵으로 일관한다면 사용자의 의무불이행에 대해서 일정한 경우에 ‘승낙’의 효과를 발생시킬 수도 있는 것이다. 당사자의 침묵이 거절을 의미하는 경우는 상대방이 의무를 이행하는 등의 방법으로 이익을 제공할 경우에 해당하는 상황이다. 궁극적으로 이 문제에 있어서 노동관행의 성립을 인정해야 할 이유는 시효제도의 존재이유와 같다. 시효제도는 일정한 사실상태가 오래 계속된 경우에 그 사실 상태를 그대로 존중하여 법률관계로 인정해주는 제도이다. 법정기간을 두고 시효의 성립을 인정하는 것과 마찬가지로 일정한 기간 이상의 사실의 반복에 대해서 노동관행의 성립을 인정하는 것은 논리적으로 아무런 문제가 없다.

상대방 당사자의 부작위로부터 기대와 신뢰가 형성되는 원리는 근로자의 의무불이행의 경우에도 동일하게 발생한다. 예컨대, 근로자가 정해진 퇴근시간보다 2-30분 정도 일찍 퇴근하는 행위를 반복하였고, 사용자가 이에 대해 경고나 징계조치 혹은 임금삭감조치를 취하지 않고 상당기간 묵인한 경우에 근로자로서는 노동관행의 성립을 주장할 수 있다. 노동관행이 성립되어 그것이 근로계약의 내용으로 되었음에

25) 권혁의 논문, 296-297쪽; 같은 취지의 견해로는 박홍규의 책, 239쪽; 김형배의 책, 100쪽

26) 당사자의 의무불이행의 경우에도 노동관행의 성립을 인정하는 견해로는 권오성 “노동관행의 법적성질에 관한 일고찰”, 「변호사(제34집)」, 대한변호사협회, 2004, 185쪽; 하경효의 책, 74쪽

도 불구하고 사용자가 근로자에 대해 징계를 하는 것은 허용될 수 없다.²⁷⁾

IV. 관련 문제

1. 규정을 넘어서는 노동관행의 성립?

(1) 당사자의 부작위로부터 노동관행의 성립을 인정할 수 있다고 하더라도 모든 경우에 일반적으로 노동관행의 성립을 인정할 수 있을까? 이는 기존에 성립되어 있는 규범(노동법령, 단체협약, 취업규칙, 근로계약)에 의해서 인정되고 있던 권리·의무관계를 부정하는 것이기도 하고, 근로자 입장에서는 기존의 근로조건을 불리하게 변경하는 문제이기도 하므로 신중한 판단이 필요하다. 이에 대해서는 해당규범이 강행규정인지 임의규정인지에 따라 달리 판단되어야 한다.

(2) 이 문제에 있어서는 대법원이 참고할만한 일반적인 기준을 제시하고 있다. 대법원은 관습법과 사실인 관습의 구별에 관한 판결에서 “사실인 관습은 사적 자치가 인정되는 분야 즉 그 분야의 제정법이 주로 임의규정일 경우에는 법률행위의 해석기준으로서 또는 의사를 보충하는 기능으로서 이를 재판의 자료로 할 수 있을 것이나 이외의 즉 그 분야의 제정법이 주로 강행규정일 경우에는 그 강행규정 자체에 결함이 있거나 강행규정 스스로가 관습에 따르도록 위임한

27) 같은 취지의 견해; 임종률, 「노동법(제14판)」, 박영사, 2014, 15쪽; 박홍규의 책 239; 일본 東京地判 1971. 9. 13. 勞民集 22권 5호 160쪽. 해당 판결에 따르면 “지각, 조퇴, 결근의 경우 임금공제를 하지 않는 것이 반복되어 당사자가 이에 따르고 있는 이상 사실인 관습으로 고용계약의 내용으로 되어 있으므로 지각을 이유로 한 임금공제는 허용될 수 없다.”고 한다.

경우 등 이외에는 법적 효력을 부여할 수 없다.”²⁸⁾고 하였고, 종원의 자격을 성년 남자로만 제한하고 여성에게는 종원의 자격을 부여하지 않았던 종래의 관습법에 대한 변경을 인정한 사안에서는 “사회의 거듭된 관행으로 생성한 사회생활규범이 법적 규범으로 승인되기 위해서는 헌법을 최상위 규범으로 하는 전체 법질서에 반하지 않는 것으로 정당성과 합리성이 있다고 인정되어야 ...”할 것²⁹⁾이라고 하였다. 이러한 판결을 통해서 보면 노동관행을 통해 새로운 규범의 성립을 인정하더라도 그것은 원칙적으로 임의규정의 영역에서만 가능할 뿐 기존의 강행규정을 넘어서서 규범의 성립을 인정할 수는 없다고 할 것이다.

3) 기존규범이 임의규정(법령 중의 임의규정, 단체협약, 취업규칙, 근로계약)의 영역에 해당하는 경우 노동관행의 성립은 해당 규범의 변경 요건(당사자의 합의 혹은 근로기준법 제94조 제1항 단서의 요건)에 준하는 정도의 노동관행의 성립요건을 충족할 필요가 있다. 이 영역에서는 당사자의 의사에 의해서 규범이 성립된 것이므로 당사자의 의사를 대체할 만한 신뢰가 형성될 정도이면 노동관행의 성립을 인정할 수 있을 것이다. 판례 중에는 근무시간 중에 상급단체의 행사에 반복적으로 참석한 사실에 대해 노동관행에 의해 근무시간 중의 조합 활동으로 인정한 사례³⁰⁾가 있고, 단체협약상의 ‘노조 사무실의 제공’과 관련된 해석과 관련하여 사용자 측이 60여 년 간 노조사무실의 전기요금을 지원한 사실이 있음에도 이를 노동관행으로 인정하지 않은 사례³¹⁾도 존재한다. 특히 후자의 사례는 하급심에서도 노동관행으로

28) 대법원 1983. 6. 14. 선고 80다3231판결

29) 대법원 2005. 7. 21. 선고 2002다1178(전원합의체)판결

30) 대법원 2003. 8. 22. 선고 2001두5767판결

31) 대법원 2014. 2. 27. 선고 2011다109531판결; “한국철도공사와 전국철도노동조합이 체결한 단체협약에 ‘공사는 조합활동을 위한 사무실을 제공한다’라고 규정하고 있는데, 노동조합이 공사를 상대로 조합 사무실의 전기요금 지급을 구한 사안에서, 단체

인정하기도 하였고, 사실관계상 충분히 노동관행으로 인정할만한 사례이기도 하였는데, 대법원은 노동관행의 성립에 법적확신에 준하는 규범의식의 존재를 요구하는 기준을 적용하여 노동관행의 성립을 인정하지 않았다. 사안이 단체협약에 의해서 규율되는 임의규정의 영역이라는 점에서 보면 대법원이 과도하게 엄격한 기준을 적용한 것으로 보인다.

4) 기존 규범이 강행규정이 존재하는 영역의 경우에는 원칙적으로 노동관행에 의해서 강행규정을 넘어설 수는 없다. 명시적인 강행규정이 있음에도 불구하고 불문의 노동관행의 성립을 인정할 수는 없기 때문이다. 노동관행의 인정근거가 신뢰 혹은 신의칙이라는 점에서도 명문의 강행규정을 넘어설 수는 없다. 다만, 대법원 판례가 예시하고 있듯이 “강행규정 자체에 결함이 있거나 강행규정 스스로가 관습에 따르도록 위임한 경우”등 극히 예외적인 경우에는 노동관행의 성립을 인정할 수 있을 것이다.

대법원은 전적에 관한 사안³²⁾에서 노동관행의 성립에 법적확신에 준하는 규범의식의 존재를 요구하여 노동관행의 성립을 인정하지 않았는데, 근로자 입장에서 사용자가 변경되는 전적에 있어서의 근로자의 동의는 강행규정의 성격³³⁾을 갖고 있다는 점에서 보면 판례가 그

협약에서 정한 ‘사무실 제공’에 사무실이라는 공간적인 시설과 사회통념상 그 안에 일반적으로 비치되는 책상, 의자, 전기시설 등 부대시설의 제공을 넘어 운영비의 성격을 지닌 전기요금의 지급까지 포함된다고 해석할 수 없을 뿐만 아니라, 전기요금 지원 관행이 공사 내에서 일반적으로 근로관계를 규율하는 규범적인 사실로서 명확히 승인되었다거나 사실상의 제도로서 확립되어 있다고 할 수 있을 정도의 규범의식에 의하여 지지되고 있었다고 볼 수 없는데도, 단체협약에서 정한 ‘사무실 제공’에는 전기요금의 지급까지 포함된다고 본 원심판결에 법리오해의 위법이 있다.”

32) 대법원 1993. 1. 26 선고 92다11695 판결; 해당 사안은 그룹 내 계열회사간의 전적이 20여 년간 계속 시행되어 왔고 현존 관리직사원의 30% 이상이 전적된 경력을 가지고 있었음에도 노동관행을 인정하지 않았다.

33) 민법 제657조(권리의무의 전속성) ①사용자는 노무자의 동의 없이 그 권리를 제삼자에게 양도하지 못한다. ②노무자는 사용자의 동의 없이 제삼자로 하여금 자기에

와 같은 엄격한 기준을 설치한 것이 이해된다. 판례 중에는 회사가 일방적으로 근로자들에 대한 상여금의 지급을 중지하고 근로자들이 상당기간 동안 이의제기를 하지 않았음에도 근로자들의 묵시적인 상여금의 포기의사를 인정하지 않은 사안³⁴⁾이 있는데, 이 역시 강행규정인 임금지급에 관한 사안인 이상 노동관행의 성립을 엄격히 제한할 필요가 있다는 점에서 이해할 수 있는 판결이다.

그에 비해 대법원은 통상임금에 관한 2013년 전원합의체 판결에서는 통상임금이 근로기준법상 강행규정임에도 불구하고 방만하게 노동관행을 인정하는 취지의 판결을 하여 해당 판결의 소수의견으로부터 비난 섞인 반론을 당하기도 하였다. 해당 판결에서는 회사 측이 노동조합과 통상임금에 해당되는 상여금을 통상임금에서 제외하는 내용의 단체협약을 체결하였고, 그에 따른 기준을 조합원이 아닌 관리직 직원들에게 적용하는 것에 대해 명시적 또는 묵시적인 노사합의 내지 관행이 있었다는 취지의 판결³⁵⁾을 하였고, 또 다른 사안에서는 상여금지급 규정이 있음에도 불구하고 회사가 퇴직자들에게 설·추석상여금을 지급하지 않은 사안에 대해서 노동조합이나 근로자들이 특별히 이의제기를 하지 않았다는 이유로 노동관행을 인정하였다.³⁶⁾ 그러나 이들 사안은 강행규정을 넘어서서 노동관행을 인정할 특별한 사정이 인정된다고 볼 수는 없다할 것이다.

2. 노동관행의 성립범위

(1) 노동관행 성립의 전제가 되는 사실의 반복은 집단적인 근로관

갈음하여 노무를 제공하게 하지 못한다. ③당사자 일방이 전2항의 규정에 위반한 때에는 상대방은 계약을 해지할 수 있다.

34) 대법원 1999. 6. 11. 선고 98다22185판결

35) 대법원 2013. 12. 18. 선고 2012다89399판결

36) 대법원 2013. 12. 18. 선고 2012다94643판결

계(사용자와 노동조합 또는 사용자와 근로자 집단)의 영역에서만 발생하는가? 아니면 개별적 근로관계에서도 발생하는가?

이에 대해서는 노동관행 성립의 집단성을 인정하는 견해가 다수인 것으로 보인다.³⁷⁾ 이들 견해는 사용자의 근로자에 대한 개별적인 취급은 근로계약의 해석의 기준은 될 수 있어도 노동관행으로 볼 수는 없다고 한다. 그러나 노동관행은 횡적으로도 종적으로도 모두 성립될 수 있다. 사용자와 개별 근로자 간에 어떠한 사실이 반복적으로 누적됨으로써 기존의 근로계약에 없거나 기존의 근로계약을 변경하는 새로운 근로계약 내용이 생성된다면 이는 반복된 사실이 상대방 당사자의 기대와 신뢰를 발생시키고 그와 같은 현상에 대해 노동관행의 성립을 인정함으로써 새롭게 근로계약의 내용이 생성되는 것으로 이론 구성할 수 있다. 이론적으로는 새롭게 근로계약의 내용으로 전환되는 매개체로서 노동관행의 성립이 선행되어야 한다.

(2) 노동관행의 성립은 개별 기업의 영역에만 머무르는가?

우리의 경우 노동운동의 역사도 짧고 단체교섭도 기업별 교섭이 일반적이었던 관계로 노동관행의 성립이 대체로 개별 기업에 한정되어 있고, 전국적이거나 일정한 지역에 분포하는 광범위한 노동관행이 인정된 사례가 존재하지는 않는다.³⁸⁾ 그렇다고 하더라도 개별 기업 이상의 영역으로 확장해서 노동관행의 성립을 인정할 필요가 있다면 굳이 노동관행의 성립을 개별 기업의 영역에 한정시킬 필요는 없을 것이다. 다만, 그 경우의 노동관행은 규범의 적용범위가 확장되므로 노동관행의 성립요건은 더 엄격하게 적용할 필요가 있다.

이와 관련해서는 두 개의 판결을 주목해 볼 필요가 있다.

37) 김형배의 책, 100쪽; 박홍규의 책, 238쪽; 김재훈, “근로조건 변경의 법리-불이익변경의 한계를 중심으로”, 서울대 박사학위 논문, 1999, 305쪽

38) 김형배의 책, 98쪽

먼저, 도급인 사업장에서 외주 용역업체 변경 시에 근로자들의 고용승계기대권을 인정하고 있는 사안들³⁹⁾의 경우를 보면, 도급업체-용역업체들-근로자들 사이에 노동관행의 성립이 인정된 것으로 볼 수 있다. 이 사안들을 보면 용역업체들 사이에서는 아무런 계약관계가 존재하지 않음에도 근로자들의 고용승계기대권을 인정하였는데, 해당 노동관계 영역에서 노동관행이 성립되었다는 것 외에는 이를 논리적으로 설명할 수 있는 별다른 근거가 존재하지 않는다.⁴⁰⁾ 이 사안을 통해서 보면 노동관행의 성립범위가 개별기업 차원보다 더 확장된 것으로 볼 수 있다.

다음으로, 퇴직자들이 단체협약의 체결에 따라 발생한 임금 및 퇴직금 인상분 차액을 청구한 사안에서 하급심은 노동관행의 성립을 인정하였으나 대법원은 회사가 퇴직자들에게 지급한 것은 단지 외부적 사정에 불과하다는 이유를 들어 노동관행의 성립을 인정하지 않았다.⁴¹⁾ 이 판결은 대법원이 현재시점에서의 고용계약관계의 존재라는 지극히 형식적인 이유를 들어 노동관행의 성립범위를 부당히 제한한 것이라 할 수 있다. 또한 이 판결은 단체협약이라는 임의규정의 영역에서 법적확신에 준하는 규범의식의 존재를 요구하는 엄격한 기준⁴²⁾

39) 서울행정법원 2013. 8. 27. 선고 2012구합41905판결(대법원 2017. 10. 12. 선고 2017두51303판결심리불속행 기각으로 확정, 이 사건의 1심 판결은 명시적으로 노동관행을 인정하였다); 대법원 2021. 4. 29. 선고 2016두57045판결

40) 손수진, “외주용역업체 변경시 고용승계관행에 관한 비판적 고찰”, 『한양법학(제30권 제1집)』, 한양법학회, 2019. 2, 209-210쪽

41) 대법원 2002. 4. 23. 선고 2000다50701판결; “원심이 내세우는 노사관행이 피고가 이미 퇴직한 근로자들에게까지 임의로 임금인상분 및 퇴직금인상분 차액을 추가 지급하여 준 사실을 말하는 것이라면, 그것은 노동조합 또는 근로자 집단과 사용자 사이에 있었던 사실이 아니라, 이미 퇴직한 근로자들과 사용자였던 피고 공사 사이에 있었던 외부적 사정에 불과하므로, 그로써 노동조합 또는 근로자 집단과 사용자 사이의 노사관행이 성립할 수도 없는 것이다.”

42) 판례는 “‘기업의 내부’에 존재하는 특성의 관행...”이라는 표현을 사용하고 있는데, 이 표현 때문에 대법원이 노동관행의 성립범위를 필요 이상으로 ‘기업 내부’로 한정하려는 것은 아닌지 의문이 든다.

을 적용하여 너무 협소하게 노동관행의 성립을 제한한 것이기도 하다.

3. 노동관행의 소멸 혹은 변경

(1) 노동관행이 성립된 경우 규범력을 발휘하므로 그 전제가 된 사실관계는 법률관계로 전환된다. 이 경우 이미 형성된 노동관행을 소멸(혹은 변경)시키기 위해서는 일반적인 근로조건 변경의 방법으로 가능하다. 노동관행이 집단성을 띠는 경우에는 단체협약의 체결이나 취업규칙의 불이익변경의 방식에 의해서 변경할 수 있다.⁴³⁾ 노동관행이 개별적으로 인정된 경우에는 별도의 합의나 계약의 방식으로 가능하다.

(2) 노동관행이 명시적인 방법이 아닌 불문의 방법, 즉 노동관행이 성립된 방식으로 소멸 혹은 변경될 수 있는가? 이 역시 규범의 변경인 이상 새로운 사실의 반복이 노동관행의 성립요건을 충족시킬 수 있다면 가능할 것이다.⁴⁴⁾ 다만, 근로조건이 불리하게 변경되는 경우에는 상대방 당사자의 ‘부작위’로부터 기대와 신뢰가 형성되는 경우이므로 노동관행의 소멸에 있어서 신중한 판단이 필요하다.

이와 관련하여 일부 견해⁴⁵⁾는 노동관행이 성립된 방식으로 노동관행이 소멸된 사례로 독일연방노동법원의 판례⁴⁶⁾를 소개하고 있다. 해당 판례의 요지는 다음과 같다. “단체협약은 월 임금의 70%를 크리스

43) 신권철의 논문, 265쪽; 하경호의 책, 76쪽

44) 한편, 신권철의 논문, 265쪽은 대법원 2001. 10. 23. 선고 2001다53950판결을 기존의 노동관행을 노동관행에 의해서 변경한 사례로 언급하고 있는데, 사실관계를 보면 ‘생산격려금의 임금성 인정, 생산격려금의 퇴직금 산정에서의 배제’라는 두 가지 사실이 하나의 노동관행에서 인정된 경우에 불과한 것으로 판결의 오독으로 보인다.

45) 권혁의 논문, 293-295쪽

46) BAG NZA 1997, 1007

마스 상여금으로 지급하도록 규정하였는데, 회사는 임의로 100%를 지급하여 노동관행이 성립되었다. 17년 뒤 사용자는 ‘크리스마스 상여금은 호의차원에서 지급받는 것이므로 근로자들이 청구권을 행사할 수 없다’고 공고하였는데, 다만 상여금은 그 뒤에도 종전대로 100%를 지급하였다. 15년 뒤 사용자는 30%를 삭감한 상여금을 지급하였고 이에 대해 근로자들이 제소하였다. 이에 대해 법원은 사용자가 상여금 지급이 호의적인 것임을 공시하였고, 근로자가 이의제기를 한 바 없으므로 기존의 노동관행은 그 후에 발생한 노동관행에 의해 소멸하였다는 근거를 들어 근로자의 청구를 배척하였다.”

그러나 이 판결은 노동관행의 법적근거를 계약설로 보든⁴⁷⁾ 신뢰책임설로 보든 기존의 노동관행이 소멸된 것으로 보기 어려운 부당한 판결이다. 해당 사안의 사실관계에서 보듯이 근로자들에게 지급된 상여금의 액수는 종전과 같이 그대로 유지되고 있으므로 새로운 노동관행의 성립전제로서 사실의 변화가 없고, 그와 같은 상태에서 사용자의 일방적인 호의성의 공시에 대해 근로자들이 적극적으로 이의제기를 할리는 만무하며, 이러한 상태에서 근로자들이 호의성의 제거라는 사용자의 일방적인 공시를 수용하고 이의제기를 하지 않을 것이라는 사용자의 기대 혹은 신뢰는 형성될 수 없다. 해당 사안에서는 기존의 노동관행이 계속되고 있었다고 보아야 한다.

V. 결론

부분사회에 불과한 노동관계의 영역에서는 민사의 영역과 달리 명시적인 규정에 의하지 않은 노동관행이 많이 성립될 수밖에 없고 그

47) 계약설의 입장에서 청약이나 승낙의 의사표시가 흠결되었다고 보는 견해; 권혁의 논문, 296-299쪽

럴 필요성도 인정된다. 이 경우 일정한 관행에 대해서 노동관행으로 인정하여 규범력을 부여하는 근거가 명확할 필요가 있다. 그런데 대법원의 판례는 다양한 근거를 사용하고 있고, 그에 따라서 노동관행으로 인정할 기준도 명확하지 않으며, 사안에 따라서는 판결의 일관성도 갖추지 못하고 있다.

노동관행에 대해서 규범력을 인정하는 근거로는 신뢰책임으로 이론 구성하는 것이 적절하다. 노동관계에서 당사자 일방이 갖게 되는 신뢰는 보호될 필요가 있으며, 이는 신의칙이라는 객관적 규범에 근거할 수 있다. 이에 의할 때 반복되는 사실에 대해서 규범력을 부여하는 논리가 자연스럽게 설명되며, 당사자의 의사나 이익 혹은 당사자가 누구인지를 불문하고 노동관행이 객관적인 규범을 형성하는 과정을 일관되게 설명할 수 있다. 이에 의할 때 노동관행에 관한 모든 사안들이 논리적으로 설명될 수 있으며, 노동관행의 성립에 대한 판결의 일관성도 확보할 수 있다.

주제어: 노동관행, 신뢰책임, 강행규정, 임의규정

【참고문헌】

- 김형배, 「노동법(제27판)」, 박영사, 2021
- 박홍규, 「고용법·근로조건법(제2판)」, 삼영사, 2005
- 이상윤, 「노동법(제6판)」, 법문사, 2011
- 이병태, 「최신노동법(제9전정판)」, (주)중앙경제, 2008
- 임종률, 「노동법(제14판)」, 박영사, 2014
- 하경효, 「노동법 사례연습」, 박영사, 2008
- 권오성, “노사관행의 법적성질에 관한 일고찰”, 「변호사(제34집)」, 대한변호사협회, 2004
- 권 혁, “노동관행에 따른 급부청구권의 형성과 소멸” 「노동법학(제23호)」, 한국노동법학회, 2006. 12
- 김재훈, “근로조건 변경의 법리-불이익변경의 한계를 중심으로”, 서울대 박사학위 논문, 1999
- 이달휴, “노동관행의 성립과 효력”, 「재산법연구(제24권 제1호)」, 재산법학회, 2007
- 하경효, 「노동법 사례연습」, 박영사, 2008
- 박수근, “노동관행의 규범성과 단체협약의 소급적 효력”, 「노동판례비평」, 민주사회를 위한 변호사 모임, 2002
- 손수진, “외주용역업체 변경 시 고용승계관행에 관한 비판적 고찰”, 「한양법학(제30권 제1집)」, 한양법학회, 2019. 2
- 신권철, “노동관행 소고 - 통상임금 산정관행을 중심으로 -”, 「노동법학(제48호)」, 한국노동법학회, 2013. 12.

[Abstract]**Theory of Labor Practices***Kim, Seong-Jin*^{*}

In the field of labor relations, which is only a partial society, many labor practices without explicit regulations are inevitably established, and its necessity is also recognized, unlike in the field of civil affairs. In this case, the basis for recognizing certain practices as labor practices and giving them normative force needs to be clear. However, the Supreme Court's precedents use various grounds, and as a result, the criteria for recognizing labor practices are not clear, and there is no consistency in judgments depending on the case.

As a basis for recognizing the normative power of labor practices, it is appropriate to construct a theory based on trust responsibility. The trust that the parties have in the labor relationship needs to be protected, which can be based on an objective norm of good faith. This naturally explains the logic of giving normative force to repeated facts and provides a coherent account of the process by which labor practices form objective norms, regardless of the intentions or interests of the parties or who they are. In this way, all matters concerning labor practices can be explained logically, and the consistency of judgments on the establishment of labor practices can be secured.

^{*} Professor of Law, Chonbuk University

Key words: Labor Practices, trust responsibility, mandatory Regulations,
discretionary Regulations